

1500783-87.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... Tem condenações por roubo e tráfico, mas já cumpriu as penas.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas, se depararam com o réu e outro homem pela via pública, os quais se mostraram nervosos ante a presença deles, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Relataram que deram ordem de parada ao réu e ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500783-87.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500783-87.2022.8.26.0537 Controle nº 622/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR ARAUJO DA CRUZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

EDMAR ARAÚJO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 37 da Lei n.º 11.343/06, porque no dia 19 de abril de 2022, por volta das 15:45 horas, na Av. Afonso Monteiro da Cruz, altura do n.º 1890, Bairro Conceição, colaborou como informante ("olheiro") com grupo, organização ou associação destinados à prática de qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, "caput" e § 1.º e 34, ambos da Lei nº 11.343/06.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia (fls. 51/53).

A defesa apresentou resposta à acusação (fls. 94/65), sendo recebida a denúncia em 15.06.22 (fls. 103/104). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, ocorrendo desistência quanto às faltantes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.ª Promotora de Justiça requereu a condenação, por entender estarem provados os

fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela reincidência e fixação de regime inicial fechado.

A Defensor Público requereu a absolvição por atipicidade (não demonstrado estar vinculado a associação criminosa) ou em caso de eventual condenação a fixação da pena no mínimo legal, compensação da reincidência com a confissão, aplicação do disposto no art. 387, §2.º, do CPP e fixação de regime diverso do fechado por não ser crime hediondo e direito de recorrer em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O acusado, na fase policial (fls. 08), confessou a prática do crime. Disse que estava no local quando um homem lhe ofereceu R\$ 100,00 para ficar na rua de cima e "olhar" se apareciam viatura ou policiais. Declarou que por ser usuário de maconha e de cocaína e estar vivendo de fazer "bico", aceitou a proposta. Falou que não estava com drogas e que as drogas estavam com o homem que as vendia, o qual estava a certa distância dele. Informou que a porção de cocaína era vendida por R\$ 10,00 e a de maconha por R\$ 5,00, e que sabia os valores por ser usuário e não sabia o valor da unidade de "crack". Relatou que em dado momento os policiais se aproximaram e o conduziram à delegacia.

Em juízo, narrou que tinha brigado com sua mulher por estar fumando "crack", saiu de casa e um rapaz ofereceu um barraco para morar. No dia seguinte, estava sentado na calçada e um rapaz pediu para ser "olheiro" e aceitou, porque estava com fome e tinha sido expulso de casa. Disse que escutou barulho de tiro, dizendo "perdeu, perdeu". O traficante fugiu. Estava desempregado. Trabalhava antes como serralheiro. Tem condenações por roubo e tráfico, mas já cumpriu as penas.

Os policiais, na fase extrajudicial (fls. 06/07), disseram que o local é conhecido ponto de tráfico de drogas, se depararam com o réu e outro homem pela via pública, os quais se mostraram nervosos ante a presença deles, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Relataram que deram ordem de parada ao réu e ao outro homem, que fugiram correndo e durante a fuga dispensaram uma pochete de cor preta. Afirmaram que lograram deter o réu, mas que o outro homem conseguiu se evadir, correndo por entre as vielas existentes no local. Falaram que realizaram revista pessoal no réu e não localizaram nada de ilícito com ele. Declararam que recuperaram a pochete dispensada pelo homem que se evadiu e no interior desta localizaram 28 tabletes de maconha, 29 invólucros de cocaína, 1 pedra de "crack" e a quantia de R\$ 10,00. Disseram que o réu confessou que estava vendendo drogas com seu colega e por isso tentaram se evadir.

Bruno (policial), em juízo, narrou que estavam em operação no local conhecido como ponto de tráfico. Avistaram o réu e mais outro homem em atitude de tráfico, um deles jogou uma pochete com drogas. Os dois tentaram se evadir, sendo detido apenas o réu. O réu confessou, dizendo que era apenas "olheiro". Não conhecia o réu anteriormente.

No mesmo sentido foi o depoimento judicial do policial Sérgio. O réu disse que era "vapor". Não conhecia o réu anteriormente.

O réu disse que não conhecia os policiais, pelo que não teriam motivos para incriminá-lo indevidamente.

Além disso, o fato da testemunha ser policial não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º 1.301.549/7- 11.ª Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, nov/02, p. 24).

O fato de o local ser conhecido como ponto de tráfico e o réu confessar que é

"olheiro" o vincula ao grupo traficante, pelo que o fato é típico.

Assim, considerando as confissões extrajudicial e judicial, a apreensão de drogas e dinheiro, que houve confissão informal para os policiais, que o local é conhecido como ponto de tráfico, diante da prova oral colhida é caso de condenação, não se podendo cogitar de atipicidade, uma vez que detido ao lado do traficante.

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos é reincidente (fls. 46 – proc. 4439-21.2011 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 19.11.18 – fls. 42; fls. 47 – proc. 98-38.2014 – trânsito em julgado à defesa em 12.12.19 – fls. 85).

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 anos de reclusão e 300 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado.

Compenso a reincidência e as confissões extrajudicial e judicial, porque ambas são preponderantes, pelo que a pena permanece inalterada.

Nesse sentido:

"A compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência é admitida conforme jurisprudência, inclusive do STJ, 6.^a Turma, HC229489-RJ, j. 29.03.12, DJE de 11.04.13, sob o fundamento de que: "ambas as circunstâncias são preponderantes nos termos do art. 67 do CP: a primeira por se ater diretamente à personalidade do agente (capacidade de assumir erros e suas consequências) e a segunda por expressa previsão legal" (Código Penal Interpretado, Julio Fabbrini Mirabete, Atlas, 8.^a ed. Atualizada, 2013, p. 395).

No mesmo sentido: RJTJERGS 229/94, JCAT 83-84/745, RT 763/667 e 738/585 (esta última também do STJ) (Id.ib., p. 395/396).

A respeito recente decisão do STJ:

Processo

AgRg no REsp 1406723 / DF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL

2013/0328868-9

Relator(a)

Ministra LAURITA VAZ (1120)

Órgão Julgador

T5 - QUINTA TURMA

Data do Julgamento

22/04/2014

Data da Publicação/Fonte

DJe 30/04/2014

Ementa

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. CONCURSO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO ERESP N.º 1.154.752/RS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do ERESP n.º 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art.

67 do Código Penal, pelo que é cabível a compensação dessas circunstâncias.

2. Agravo regimental desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental. Os Srs. Ministros Jorge Mussi, Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro e Regina Helena Costa votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Inaplicável a redução do art. 33, § 4.º, uma vez que esta incide apenas em relação ao tráfico, previsto no art. 33, além do réu ser reincidente, de forma que não preencheria os requisitos legais (não é primário), que são cumulativos.

O entendimento deste juízo é no sentido de que a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, já que o acusado estava vinculado ao grupo

traficante, colaborando como informante ("olheiro") para a prática de tráfico, crime este de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Além disso, o réu é reincidente, pelo que o regime inicial de cumprimento da pena de qualquer forma é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, §2º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 46 – proc. 4439-21.2011 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 19.11.18 – fls. 42) e por roubo (fls. 47 – proc. 0000098-38.2014 – trânsito em julgado à defesa em 12.12.19 – fls. 85), o que denota personalidade voltada à prática de crimes, bem como não comprovou possuir ocupação lícita, o que demonstra que o crime é seu meio de vida.

Inviável a conversão em restritiva de direitos, por ser reincidente específico.

Incabível o "sursis", por não preencher os requisitos do art. 77, inc. I, do Código Penal.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente.

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência, inclusive específica (circunstância judicial agravante) e diante da pena restante a ser cumprida, não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO EDMAR ARAÚJO DA CRUZ, à pena de 2 (DOIS) DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO e 300 (TREZENTOS) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 37 da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa, é incabível qualquer benefício conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03), por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03). Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 26 e 68 – R\$ 10,00) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União, providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto à bolsa preta da marca "Nike", apreendida (fls. 26) e já periciada (fls. 96/97), tendo em vista que não possui valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessa mais aos autos, podendo ser eliminada.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 58) e providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06).

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e comunicações de praxe.

Diadema, 27 de junho de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA